

1500219-14.2022.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500219-14.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

CARLOS DANIEL FRANÇA NUNES DA SILVA e DAVID JOSE FERNANDES JUNIOR

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DAVID JOSE FERNANDES JUNIOR e CARLOS DANIEL FRANÇA NUNES DA SILVA foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal porque no dia 19.06.2022, por volta da 00h30min, na Estrada Gentil Pérez, Jardim Umuarama, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 250 (duzentos e cinquenta) porções da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, 28 (vinte e oito) tiras de maconha com peso total de 239 gramas, 252 (duzentos e cinquenta e duas) porções de cocaína e 227 (duzentas e vinte sete) pedras de crack, derivado da cocaína, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14.07.2022 (pág. 128).

Os réus foram citados (págs. 141 e 144) e apresentaram respostas escritas à acusação (págs. 147/152 e 159/165).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas pela defesa e ao final foram realizados os interrogatórios dos réus (págs. 217/219).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às págs. 116/118.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se os acusados nos exatos termos da denúncia.

A defesa de David José Fernandes Junior, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou ainda, seja reconhecido o privilégio, conforme §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, ou em caso de eventual condenação, que sejam observadas as atenuantes, convertendo a pena em restritiva de direitos.

A defesa de Carlos Daniel França Nunes Da Silva, requereu a absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal ou, absolvido com base no mesmo artigo, inciso VII. Por fim, que o réu possa apelar em liberdade e, em caso de eventual condenação, que sejam aplicadas todas as atenuantes previstas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 04), pelo boletim de ocorrência (págs. 13/18), pelo auto de exibição e de apreensão (págs. 19/20), pelo auto de constatação preliminar (págs. 21/22), pelo laudo químico- toxicológico (págs. 116/118), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Luis Antonio Sanches, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que avistaram um veículo Onix trafegando com os faróis apagados, momento em que acenderam a lanterna em direção ao veículo e puderam visualizar que um deles se abaixou, motivo pelo qual realizaram a abordagem e, em vistoria no interior do veículo, encontraram os entorpecentes descritos nos autos. Disse que em revista pessoal, com o condutor, nada de ilícito fora encontrado, contudo, em posse do passageiro foram encontrados dois saches contendo cocaína. Informou que indagados, confessaram a prática delitiva.

A testemunha arrolada pela acusação, Thiago Gonzales Guedes Correa, Policial Militar, ouvido em Juízo, apresentou os mesmos fatos que seu colega de farda.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar os réus. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las. 'O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E

a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câ. V.U. 31.07.2008)'. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Aferes-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes que somada às demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

A testemunha arrolada pela defesa, Leda Rosa Pucci ouvida em Juízo, disse que conhece David há mais de 20 (vinte) anos e ele sempre foi uma pessoa idônea, bom pai e bom filho. Informou, ainda, que ele sempre foi trabalhador.

A testemunha arrolada pela defesa, Midian Carina de Almeida Silva, ouvida em Juízo, disse que conhece David desde criança e ele sempre foi trabalhador, uma pessoa boa. Relatou que ficou surpreendida com a prisão do réu.

O réu, David Jose Fernandes Junior, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos da denúncia. Disse que trabalhava como motorista de aplicativo e fora contratado por uma pessoa de nome Rogério para levar a encomenda para a cidade. Negou ter conhecimento do que havia dentro do pacote, visto que a norma da empresa é de que não viole o pacote dos clientes. Relatou que o corréu veio para acompanhá-lo e conhecer a praia.

O réu, Carlos Daniel França Nunes Da Silva, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos da denúncia. Disse que estava com um saquinho de cocaína em sua posse, mas o corréu David não sabia. Relatou que veio junto para conhecer a praia e asseverou que David relatou que estava vindo a praia para realizar a entrega de uma encomenda. Negou ter ciência de que havia entorpecentes no automóvel.

Pois bem.

Embora os réus tenham negado a autoria, suas versões não merecem arrimo em vista dos depoimentos colhidos em Juízo, posto que os policiais confirmaram que os acusados admitiram a prática delitiva.

Ademais, em sede extrajudicial tem-se que o corréu David renovou os fatos narrados aos policiais, conforme termo de interrogatório de pág. 10, o qual o acusado relata que transportava os entorpecentes para abastecimento do ponto de venda de drogas localizado no bairro Jardim Coronel.

Desse modo, tem-se que a responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Outrossim, não se produziu qualquer prova apta a fomentar as alegações produzidas pelos acusados.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“TÓXICOS – Tráfico – Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha – Ausência de prova direta da finalidade mercantil – Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. – Recurso conhecido e provido.” (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU DAVID JOSE FERNANDES JUNIOR

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 75/76) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei

n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU CARLOS DANIEL FRANÇA NUNES DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 79) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o

acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto, CONDENO o réu DAVID JOSE FERNANDES JUNIOR qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Ainda, CONDENO o réu CARLOS DANIEL FRANÇA NUNES DA SILVA qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomende-se os réus na prisão em que se encontram, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder dos réus em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se os réus para efetuar o pagamento da multa.

Condene-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 19 de dezembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA